

1500428-79.2021.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... necessário à condenação pela prática do tráfico de drogas, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a notícia recebida pelos policiais de que o acusado realizava o tráfico, a quantidade e forma de embalagem do entorpecente apreendido, bem como a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500428-79.2021.8.26.0580- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500428-79.2021.8.26.0580 - 2021/003010

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMANUEL GUSTAVO DA CUNHA NUNES

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1.EMANUEL GUSTAVO DA CUNHA NUNES, qualificado nos autos (fl. 15), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque na data, horário e local descritos na denúncia, na Cidade de Tarumã, nesta Comarca, supostamente, mantinha em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 24 (vinte e quatro) porções de crack, com peso líquido de 8,73 g (oito gramas e setenta e três centigramas), além de 3 porções de cocaína, com peso líquido total de 29,76 g (vinte e nove gramas e setenta e seis centigramas) [fls. 148/151].

Não houve proposta de acordo de não persecução penal (fl. 145).

O acusado constituiu defensor (fl. 161) e, após a apresentação de defesa preliminar (fls. 177/191), a denúncia foi recebida (fls. 209/212).

Em instrução foram inquiridas três testemunhas comuns e uma arrolada pela defesa e o réu interrogado (fls. 286/288 e 292).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação, nos termos da denúncia (fl. 292) e da d. Defensora, preliminarmente, alegando cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de realização de exame toxicológico, e no mérito, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela

desclassificação para a imputação descrita no art. 28 da Lei 11.343/06, ou, ainda, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, e pela restituição do celular e dinheiro apreendidos (fls. 305/309). É o relatório.

2. A alegação de cerceamento de defesa, pela não realização de exame toxicológico, já foi analisada nos autos, consoante decidido na audiência realizada em 15/02/2022 (fls. 286/288), nos seguintes termos:

[...] a realização do exame de dependência toxicológica somente é necessária quando o juiz, em seu prudente juízo de discricionariedade e pela atenta observação do acusado, conceber que seu vício lhe impinge uma anormalidade psíquica relevante, de modo a atingir sua capacidade de autodeterminação e, em consequência, afetar sua culpabilidade. Assim, o exame em questão deve ser feito em sendo observada alguma anormalidade que pudesse diminuir a capacidade de raciocínio do acusado, para verificar, se à época dos fatos, era dependente químico e por isso era, inteira ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta. Pelo teor do interrogatório do acusado conclui-se que esse possui e possuía, à época dos fatos, plena capacidade de entendimento e raciocínio. Naquela oportunidade, respondeu a todas as perguntas dentro da maior normalidade, não deixando qualquer suspeita sobre sua capacidade de compreensão da ilicitude do fato e de autodeterminação. Tanto que ao ser inquirido, afirmou que trabalhava normalmente na época dos fatos, com o seu pai, inclusive apontando que o dinheiro apreendido era fruto do seu trabalho. Assim, não vislumbro nenhum indício que possa colocar em dúvida a capacidade mental do denunciado quando do crime, capaz de ensejar a realização do exame pericial a respeito. Ademais, a simples alegação de uso de drogas, por si só, sem qualquer prova neste sentido, não é indício suficiente para determinar a realização do exame de dependência toxicológica. Nestes termos, indefiro o pedido de realização de exame toxicológico.

Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE (LATROCÍNIO). NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL (TOXICOLÓGICO). NULIDADE NÃO VERIFICADA. Uma vez que a realização de exame de sanidade mental - toxicológico - é faculdade do Julgador, cabendo a ele avaliar a sua necessidade, ordenando-o, tão somente, quando houver incerteza da capacidade de autodeterminação e higidez mental do agente e tendo o Magistrado justificado o indeferimento em razão da inexistência de dúvidas quanto ao comprometimento da capacidade de entendimento do agente, inexiste nulidade a ser sanada. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO- PROCESSO CRIMINAL, Recursos; Apelação Criminal: 01260086020178090176 NOVA CRIXÁS, Relator: Des(a). Adegmar José Ferreira, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 03/05/2021) (grifo nosso).

Confira-se, a propósito:

4. As provas colhidas permitem concluir que o agente tinha plena capacidade de entendimento em relação ao crime praticado, sendo despicienda a realização de exame toxicológico para avaliá-la, cabendo ao juiz da causa decidir pela necessidade e conveniência de sua realização. (TJ-DF-PROCESSO CRIMINAL, Recursos; Apelação Criminal: 00078332320168070007, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Data de Julgamento: 27/04/2017 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJE de 05/05/2017).

Logo, à míngua de fatos novos, fica mantida a decisão que indeferiu o pedido de realização de exame de verificação de dependência toxicológica no acusado.

Rejeito, dessarte, a preliminar arguida.

2.1. A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 34/35), bem como pelos laudos periciais (fls. 51/53, 169/171, 273/275 e 276/285).

Na fase policial o acusado aduziu que não é usuário, só fuma maconha, que confessa que as drogas são suas, que mostrou o que tinha na casa, que quando a polícia chegou estava dormindo, que só sobre das pessoas que estavam na sua casa quando acordou. Que tem passagem por tráfico e furto. Que só vende, e não usa aquelas drogas, que não pega bala dos outros, pega porção grande para fracionar, e o que ganhar em cima é dele (fl.15).

Em Juízo o réu aduziu que foi coagido pelos castrenses na fase policial. Afirma que a droga era para uso pessoal e não para comercialização. Atualmente tem 18 anos. Conhecia os policiais por abordagens de rotina que eram realizadas em Tarumã. Afirma que todas as pessoas que estavam no local dos fatos estavam usando drogas. João Paulo é 'primo distante' do réu. O local do ocorrido era a casa do interrogado, onde morava sozinho. Disse que a quantidade de entorpecente encontrada na residência era para todas as pessoas que estavam ali presentes usarem, não apenas o interrogado. Nega que os policiais tenham encontrado as drogas em sua posse, pois os entorpecentes estavam em cima da mesa de mármore que fica na casa dos fundos. Afirma que os utensílios encontrados na casa eram destinados para o uso e não para mercancia. O dinheiro encontrado com o réu era referente a uma diária de serviço prestado ao pai, que é construtor civil. O interrogado afirma que se considera viciado em crack e cocaína (fls. 286/288).

O Policial Militar Luciano obtemperou que se deslocou até Tarumã, pois tinha mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do acusado, e havia informações de que o réu estava praticando o tráfico de drogas na cidade. O depoente visualizou o réu no portão da casa. A testemunha entrou na residência pelo muro lateral do imóvel e realizou a abordagem do acusado no quarto dele. O réu confessou que estava praticando o tráfico de drogas e prontamente entregou os entorpecentes ao depoente. Continha crack e cocaína. Na posse do réu tinha a quantia de R\$ 73,00 e um aparelho celular, que havia sido cedido ao acusado para a prática da conduta delituosa. Na residência, o depoente encontrou mais três indivíduos que teriam afirmado que foram até o local comprar e utilizar drogas. Em vistoria pela casa, foi encontrado prato, tesoura e outros utensílios utilizados para embalar o entorpecente. O acusado era conhecido nos meios policiais. O depoente nunca tinha abordado ele anteriormente (fls. 286/288).

No mesmo diapasão foi o depoimento do Policial Militar Anderson, tendo acrescentado que as drogas foram encontradas dentro do tênis do acusado, que foram entregues pelo réu nas mãos do Sargento Maciel (fls. 286/288).

A testemunha Carla Cristina, arrolada pela defesa, asseverou que é tia do réu.

Quando a depoente chegou no local dos fatos, a polícia já estava lá. Tem conhecimento que o acusado 'perdeu o controle' após começar a usar drogas. O réu trabalhava em um escritório de contabilidade, tendo sido demitido durante a pandemia. O acusado morava sozinho no imóvel onde os fatos ocorreram, pois o réu se distanciou da família devido ao uso de droga. O acusado era viciado. As pessoas que estavam presentes no dia dos fatos estavam usando entorpecentes junto com o réu. Os policiais de Tarumã perseguiam o acusado (fls. 286/288).

A testemunha Gabriel Henrique disse que conhece o réu em razão do vício da droga. A testemunha estava na casa do acusado quando os policiais abordaram o réu e encontraram as porções de droga. Nunca viu o acusado vendendo drogas, apenas consumindo. Afirma que todas as pessoas que estavam na residência do réu eram usuárias (fl. 292).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação do acusado é medida de rigor, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia foram ratificados pela prova oral, arrolada pela acusação.

É sabido que não se pode relegar ao oblivio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Desse modo para que o testemunho policial deixe de ter presunção de credibilidade, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente alegações desacompanhadas de elementos de convicção.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS

RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - VALOR PROBANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - AUSÊNCIA REQUISITOS. - Restando comprovadas a materialidade e autoria, mostra-se descabida a pretensão absolutória ou desclassificatória, pois não obstante tenha alegado o réu ser a droga apreendida de propriedade de outro indivíduo, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, já que não logrou êxito em demonstrar que as substâncias encontradas eram de outra pessoa ou, até mesmo, que o paciente é apenas usuário. - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura, ônus da defesa. - Ausente os pressupostos legais da incidência da minorante descrita no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, não há que se falar em redução da pena no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). (TJ-MG - APR: 10701130115929001 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014).

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do tráfico de drogas, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a notícia recebida pelos policiais de que o acusado realizava o tráfico, a quantidade e forma de embalagem do entorpecente apreendido, bem como a apreensão de dinheiro e dos petrechos utilizados no preparo das drogas, o que bem demonstra a finalidade de mercancia, ressaltando-se, ainda, a confissão extrajudicial, quando da abordagem policial.

Outrossim, ad argumentandum, vale ressaltar que a confissão extrajudicial deve prevalecer sobre a retratação judicial, uma vez que, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, confere maior credibilidade à primeira, se a segunda se apresenta divorciada do conjunto probatório, mesmo porque a confissão de autoria vale, não pelo lugar em que é prestada, mas, pela força de convencimento que possui (cf. TJMG - APR: 10702041186777001 MG, Relator: Paulo César Dias, Data de Julgamento: 13/05/2014, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/05/2014).

Nunca é demais lembrar que sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova (cf. TJSP - Ap. Criminal nº 990.08.011.986-9 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 09.12.2008 - v.u.).

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecente, de rigor a prolação de decreto condenatório, não se tratando de hipótese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

2.2. Passo à dosimetria da pena.

O acusado é primário, inobstante ter passagens pela Vara da Infância e Juventude, em razão de prática de atos infracionais análogos aos delitos de furto e tráfico de drogas (cf. Certidões e F.A de fls. 59/62 e 246/269).

A pena base é fixada no mínimo legal.

Não há agravantes e eventual atenuante não pode diminuir a pena aquém do mínimo legal.

In casu, não há como cogitar se aplicar a causa especial de redução de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Vale ressaltar que para fazer jus à referida redução de pena é preciso que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. A habitualidade no tráfico de drogas não se confunde com antecedentes criminais. Logo, atos infracionais praticados na menoridade servem de parâmetro para análise da dedicação do réu a atividades criminosas com habitualidade e justificam o afastamento do benefício da diminuição da pena previsto no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas.

In casu, o réu se dedica a atividades criminosas (tráfico) desde a adolescência;

logo, não faz jus à sobredita causa de diminuição.

Na mesma esteira, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. PACIENTE COM PLENA CAPACIDADE DE COMPREENSÃO DO CARÁTER ILÍCITO DO FATO A ELE IMPUTADO E DE DETERMINAR-SE CONSOANTE TAL ENTENDIMENTO. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. (AgRg no Resp 1560667/SC, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). 2. O Colegiado de origem afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006 à espécie por entender que o acusado ostentava plena capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato a ele imputado e de determinar-se consoante esse entendimento, apesar da dependência química constatada, não havendo falar, pois, em reconhecimento da semi-imputabilidade. 3. A pretensão de valorar de modo diverso demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. (HC 273.879/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 466681 MS 2018/0222049-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019).

A propósito, o seguinte precedente:

"[...] 1. Embora atos infracionais não possam ser considerados como maus antecedentes e nem se prestem para induzir a reincidência, inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4, da Lei n. 11.343/06 quando demonstrado que a paciente praticou, de forma reiterada, diversos atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de entorpecentes, vez que tais elementos "servem para demonstrar a propensão da agente ao cometimento de delitos dessa natureza" e a sua dedicação a atividades criminosas, deixando de preencher um dos requisitos legais para a incidência do benefício. 2. Ordem denegada."(HC 121509/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/3/2010).

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3.Posto isso,

Julgo parcialmente procedente o pedido acusatório para condenar EMANUEL GUSTAVO DA CUNHA NUNES, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecido em lei especial.

Deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

O montante da pena corporal desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diante do tempo transcorrido desde a prisão e do regime fixado para o cumprimento da pena, concedo o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se alvará de soltura clausulado, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a prisão preventiva é incompatível com regime semiaberto, tendo em vista que "fixar o regime semiaberto e manter a prisão preventiva do recorrente, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representa a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele que foi estabelecido na instância ordinária, caso ele opte por recorrer" (cf. AgRg no RHC 142.615/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

Como consequência da condenação, nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do dinheiro e do aparelho celular – em favor da União (fls. 34/35).

Nunca é demais lembrar que deve ser decretado o perdimento de bens em favor da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos lícitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime (cf. TJSP, Apelação nº 0203363-94.2010.8.26.0346, 2ª Câmara, Relator o Desembargador Paulo Antônio Rossi, j. em 13/02/2012).

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Publique-se, intímese e cumpra-se.

Assis, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA